

<문제-1> 디지털데이터팩토리 문제**I. 설문(1)**

1. 문제의 소재
2. 식별력이 없다는 乙 주장의 타당성 - 부당 (약하게)
 - (1) 보통명칭의 의미 判例
 - (2) 기술적 표장의 의미 및 기술성의 판단기준 判例
 - (3) 사안의 경우 (*)
3. 상표가 비유사하다는 乙 주장의 타당성 - 부당
 - (1) 상표 유사판단의 일반원칙 判例 (*)
 - (2) 외관·호칭·관념 (약하게)
 - 1) 외관·호칭·관념의 고려방법 判例
 - 2) 문자상표의 일반적·구체적 거래실정 判例
 - (3) 전체관찰의 원칙 (*)
 - 1) 전체관찰의 원칙 判例
 - 2) 검토
전체관찰이 원칙이므로, 식별력 없는 부분을 제외하고 판단할 수 없음
 - (4) 요부관찰의 법리 (*)
 - 1) 요부의 개념 및 요부관찰의 필요성 判例
 - 2) 요부결정의 소극적 기준 判例
 - 3) 요부의 전제로서 식별력 유무의 판단기준 判例
 - 4) 요부결정의 적극적 기준 判例 (*)
 - (5) 구체적 출처혼동
 - 1) 구체적 거래실정의 구별기준 (약하게)
 - 2) 침해소송에서의 구체적 출처혼동 판단방법 判例 (*)
 - 3) 검토
 - (6) 소결 (*)
“디지털 데이터 팩토리” 부분은 등록상표의 지정상품에 대하여 식별력이 없지 않고, 설령 식별력이 없더라도 제외하고 판단할 수 없고 전체로서 관찰해야 하며, 요부가 존재하므로 요부를 기준으로 판단하면, 양 상표는 유사
4. 서비스가 비유사하다는 乙 주장의 타당성 - 부당 (*)
 - (1) 서비스 간 유사여부 판단기준 判例
 - (2) 사안의 경우
5. 설문(1)의 해결 - 乙 주장은 모두 부당

강사 의견 설문의 문언해석상 “乙 주장의 타당성”을 판단해야 하는 문제이며, 그 중 “상표의 유사” 및 “서비스의 유사”를 보다 비중 있게 기재해야 하는 문제입니다. 다만, 식별력에 관한 주장을 제90조에 관한 묵시적 주장으로 볼 여지도 있어서, **제90조의 효력제한에** 관하여 기재한 경우 **추가 득점**을 받을 수 있을 것으로 생각합니다.

II. 설문(2)

1. 정당한 사용이라는 乙 주장의 타당성

- (1) 문제의 소재
- (2) 학설의 대립
- (3) 종래 판례의 태도
- (4) 전원합의체 판례의 태도 (*)
- (5) 검토
- (6) 사안의 경우 - 乙 주장 부당 (*)

2. 손해배상 청구소송에서 고의·과실 입증책임

(1) 고의의 입증책임

- 1) 고의의 추정 규정 (法112조)
- 2) 사안의 경우 (*)

“침해행위에 대한 고의”는 추정되지 않으므로, 상표권자 甲이 입증책임을 짐

(2) 과실의 입증책임

- 1) 과실의 추정 判例 (*)
- 2) 과실의 추정 복명 방법 判例 (*)
- 3) 사안의 경우 (*)

상표권자 甲이 여전히 과실에 대한 입증책임을 지나, 침해행위가 있으면 침해행위에 대한 과실은 사실상 추정되며, 침해자 乙은 침해를 정당화할 수 있는 사정을 증명하여 사실상 추정을 복명시킬 수 있음

강사 의견 데이터팩토리 전원합의체 판결의 법리를 충실히 기재하고 이와 관련된 학설/종래 판례를 적절히 추가하여 풍부하게 기재할 필요가 있었습니다. 또한, 설문의 문언해석상 과실의 추정 및 복명 외에 **고의의 입증책임**에 관해서도 간략히 기재할 필요가 있다고 생각합니다.

<문제-2> sodami 문제

I. 설문(1)

- 1. 문제의 소재 - 무효심판의 청구인적격 (法117조)
- 2. 무효심판에서 이해관계인의 판단기준 判例 (*)
- 3. 설문(1)의 해결 (*)

II. 설문(2)

- 1. 法34조1항13호의 의의
- 2. 判例가 실시한 法34조1항13호의 취지 (*)
- 3. 적용요건 (관련 판례 적절히 기재) (*)
 - (1) 특정인의 출처로 인식
 - (2) 상표의 동일 또는 유사
 - (3) 부정한 목적
- 4. 설문(2)의 해결 - 인식도로 인해 결론 오픈 (*)

III. 설문(3)

- 1. 法34조1항20호의 의의
- 2. 判例가 실시한 法34조1항20호의 취지 (*)
- 3. 적용요건
 - (1) 동업·고용 등 계약관계나 거래관계 또는 그 밖의 관계
 - (2) 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표 (*)
 - 1) 원칙 (국내 사용)
 - 2) 제3자가 국내에서 판매한 경우 判例
 - 3) 검토
 - (3) 알고 있을 것
 - (4) 상표의 동일 또는 유사
 - (5) 상품의 동일 또는 유사
- 4. 설문(3)의 해결 - 인용 (*)

강사 의견 설문(1)은 무효심판의 이해관계인에 관한 판례, 설문(2)는 法34조1항13호의 각 적용요건에 대한 일반론, 설문(3)은 法34조1항20호의 “국내 사용 또는 사용 준비”와 관련하여 최근 선고된 masmi 판례를 묻는 다소 명료한 문제였으며, 배점에 맞게 적절히 강약조절을 하면서 각 설문에서 묻는 주된 내용을 부각하여 적으면 좋은 점수를 받을 수 있을 것으로 생각합니다.

<문제-3> 제주감귤주스 문제**I. 설문(1)**

1. 甲의 “제주감귤주스”가 식별력이 없는 상표인지 여부 (적극)
 - (1) 法33조1항3호의 의의 취지
 - (2) 기술성의 판단기준 判例
 - (3) 사안의 경우 (※)
2. 사용에 의한 식별력 취득으로 등록을 받을 수 있는 요건
 - (1) 法33조2항의 의의 및 취지
 - (2) 엄격 해석의 원칙 判例 (※)
 - (3) 적용요건① - 法33조1항3호 내지 6호에 해당
 - 1) 원칙
 - 2) 法33조1항1호·2호의 취급
 - 3) 法33조1항7호의 취급 判例
 - (4) 적용요건② - 출원 전부터 상표를 사용 (※)
 - (5) 적용요건③ - 특정인의 출처표시로 식별 (※)
 - 1) 사용에 의한 식별력 취득의 판단요소 判例
 - 2) 사용에 의한 식별력 취득 판단의 유력한 증거자료 判例
 - 3) 실사용상표의 사용실적 고려가부 判例
 - 4) 출원인 외 제3자의 사용실적 고려가부 判例
 - 5) 검토
엄격 해석 but 사회통념상 출원상표/출원상품/출원인과 동일한 상표/상품/주체의 사용실적 참작 가능
 - (6) 적용요건④ - 사용한 상표를 사용한 상품에 한정하여 출원 (※)
 - 1) 법률 규정 (法33조2항)
 - 2) 검토
사용상표 및 상품과 엄격하게 동일한 상표 및 상품을 출원하여야 함
3. 설문(1)의 해결 - 등록 가능 (적절히 사안 포섭, “과실음료”를 “감귤주스”로 한정하는 내용도 언급 가능) (※)

강사 의견 法33조2항이 엄격한 해석 및 적용을 요구하는 조문임을 대전제로, 法33조2항의 적용요건에 관한 쟁점들을 풍부하게 언급하는 문제였으며, 설문의 문언해석상 품질오인염려는 심사관이 지적을 하지 않았고, 설문에서 “사용에 의한 식별력 취득을 이유로”라는 한정 문구가 있다는 점에서 法34조1항12호전단은 **출제의 의도가 아니었을** 것으로 생각합니다. 다만, 하위개념에 해당하는 “감귤주스”에만 사용 및 식별력 취득 후 상위개념에 해당하는 “과실음료”를 지정하여 출원하였는데 하위개념 상품과 상위개념 상품은 실무상 사회통념상 동일한 상품에 해당하므로 적용요건④를 충족시키기 위해 “**감귤주스로 한정보정을 해야 한다**”는 내용을 언급하는 것은 득점이 가능한 부분으로 생각합니다.

II. 설문(2)

- 1. 사용에 의한 식별력 취득의 판단기준
 - (1) 주체적 기준 (*)
 - 1) 판단기준 判例 (지정상품에 관한 일반거래자나 수요자들의 평균적인 인식 기준)
 - 2) 검토
 - (2) 객체적 기준
 - 출원상표 및 지정상품을 기준으로 판단
 - (3) 시기적 기준 (*)
 - 1) 판단기준 判例 (등록결정시)
 - 2) 검토
 - (4) 지역적 기준 (*)
 - 1) 判例
 - 2) 심사기준
 - 3) 검토
- 2. 설문(2)의 해결

III. 설문(3)

- 1. 문제의 소재 (상표권의 예외적 독점·배타성 vs 자유로운 사용 보장)
- 2. 判例의 태도 (*)
- 3. 검토
- 4. 설문(3)의 해결 - 乙 주장 부당

강사 의견 설문(1)과 구분하여, 설문(2)에서는 **일반적 판단기준**을 물은 것으로 이해되며, **주체적/시기적/지역적 기준**에 관한 판례를 기재하는 것이 중요한 부분이었습니다. 설문(3)의 경우 **재능교육 판례**를 언급하면서 “예외적으로 독점권을 부여받은 상표권”과 “자유로운 사용을 하는 사용상표” 간의 권리관계를 고찰하는 듯한 답안을 기재하면 좋은 점수를 받을 수 있을 것으로 생각됩니다.

<문제-4> 일회용 카메라 문제

I. 설문(1)

- 문제의 소재
- Y가 상표로 기능한다는 주장
 - 상표적 사용의 의의
 - 상표로서 사용되고 있는지 여부의 판단기준 判例 (*)
 - 사안의 경우 (*)
- 권리소진이 되었다는 주장
 - 권리소진의 의의 및 취지
 - 권리소진의 성립요건 判例 (*)
 - 사안의 경우
- 설문(1)의 해결 (*)

II. 설문(2)

- 문제의 소재
- X도 상표로 기능한다는 주장
- 권리소진이 되지 않았다는 주장
 - 원래의 상품과의 동일성이 유지되지 않는 경우 判例 (*)
 - 동일성을 해할 정도의가공이나 수선에 해당하는지의 판단방법 判例
 - 사안의 경우
- 설문(2)의 해결 (*)

III. 설문(3)

- 문제의 소재
- 상표법상 침해로 볼 수 있는지 여부 (소극)
 - 상표권 침해의 의의 (法89조, 法108조1항1호) (*)
 - 사안의 경우
- 전용권의 침해로 볼 수 있는지 여부 (제한적 적극)
 - 일본 판례
 - 검토 (*)
상표의 본원적인 기능을 훼손하는 것도 상표권의 침해로 본다면, 침해 긍정
- 설문(3)의 해결 (*)

강사 의견 설문(1) 및 설문(2)는 상표적 사용 및 권리소진에 관한 각 당사자의 주장을 설문별로 적절히 분배하여 논리 구성을 하는 문제였습니다. 설문(3)의 경우 “상표 바꿔치기”를 의도하고 출제된 것으로 보이나, 국내에서 이를 명시적으로 다루는 법리가 없으므로 “전용권 침해” 여부는 “상표를 상품에 부착할 권리의 침해” 또는 “기능 훼손”이라는 키워드를 언급하여 포섭하면 대체로 비슷한 점수가 부여될 것으로 예상됩니다.